

1500186-58.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... dos fatos, visando repreender o tráfico de drogas na comunidade conhecida como "favela do caixote", ponto tradicional de venda e consumo de entorpecentes, situado às margens do Rio Preto, local de difícil acesso, que dificulta as ações policiais. Narraram que, visando surpreender os agentes do tráfico, a equipe se dividiu em duas e acessou a comunidade pelas trilhas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500186-58.2021.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500186-58.2021.8.26.0633

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO PEREIRA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

CARLOS EDUARDO PEREIRA e RICARDO PEREIRA foram denunciados como incursos no crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal, porque, conforme constou, no dia 23 de junho de 2021, às 11 horas, na Rua Beira Rio, nº 01, Caraguava, local conhecido como "Favela do Caixote", nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, em unidade de desígnios e comunhão de propósitos e contando com a participação de JOSÉ DOMINGOS JESUS DOS SANTOS, teriam trazido consigo, guardado e vendido, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 303 microtubos de cocaína, com peso bruto de 347,82 gramas, 203 porções de maconha, com peso bruto de 446,77 gramas, 52 porções de crack, com peso bruto de 58,84 gramas, e 13 porções de Maconha, do tipo skunk, com peso bruto de 18,73 gramas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

JOSÉ DOMINGOS JESUS DOS SANTOS foi denunciado como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 e o artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal, porque teria concorrido para a prática do crime acima descrito, na medida em que exercia a função conhecida como "olheiro", a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada

em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 201/203), os réus foram citados (fl. 291, fl. 293 e fl. 295) e ofertaram resposta à acusação (fls. 302/305).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 306), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 309/310), na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogados os acusados.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição dos réus e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/90, pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 10/11), pelo laudo pericial (fls. 278/280), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 5), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais, nas fases policial e judicial, confirmaram a versão da acusação. Os policiais disseram que, na data dos fatos, teriam se dirigido até o local dos fatos, visando reprimir o tráfico de drogas na comunidade conhecida como "favela do caixote", ponto tradicional de venda e consumo de entorpecentes, situado às margens do Rio Preto, local de difícil acesso, que dificulta as ações policiais. Narraram que, visando surpreender os agentes do tráfico, a equipe se dividiu em duas e acessou a comunidade pelas trilhas existentes no interior do matagal que cerca a comunidade. Alegaram que, num determinado ponto, puderam avistar a ação dos traficantes, possibilitando até mesmo captar filmagens onde, de maneira cabal, identificaram um indivíduo com uma bolsa a tiracolo (utilizando boné azul e branco), recebendo usuários de drogas; um segundo indivíduo recebendo e guardando o dinheiro consigo (utilizando boné marrom); e um terceiro homem guardando os demais em ação típica de "olheiro" (utilizando boné colorido).

Disseram que optaram pela aproximação e abordagem, sendo detido de pronto o homem que estava com a bolsa, bem como o olheiro, tendo o segundo homem empreendido fuga em direção à mata, que foi alcançado logo adiante sem nada consigo. Explicaram que no interior da bolsa foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, entre eles: crack, cocaína, maconha etc. Afirmaram que, no local onde os indivíduos estavam posicionados, teriam localizado uma sacola de plástico, escondida, com mais entorpecentes diversos. Disseram que o homem que trazia a bolsa consigo foi identificado como sendo CARLOS EDUARDO PEREIRA; o segundo homem que recolhia o dinheiro como sendo RICARDO PEREIRA; e o olheiro como sendo JOSÉ DOMINGOS JESUS DOS SANTOS, todos com antecedentes criminais pelo delito de tráfico de drogas.

O réu Carlos Eduardo confessou que traficava no local há cerca de 6 meses. Mas seu histórico e comportamento revelam que exercia a traficância há muito mais tempo.

Os réus Ricardo e José negaram o delito, apresentando uma versão bastante inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Os elementos de informação do inquérito foram integralmente confirmados em audiência. Os policiais que participaram da operação deram detalhes do comportamento dos réus. Explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". Restou demonstrado que os réus atuavam de forma especialmente organizada, com divisão de tarefas. Os acusados estavam na posse de grande quantidade de drogas e em local amplamente conhecido no meio policial pela atividade da traficância. Ficou claro em audiência a comunhão de propósitos entre os réus, para a prática do tráfico de drogas.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas.

A condenação é de rigor.

Passo à individualização das penas.

RÉU CARLOS EDUARDO PEREIRA

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que os tipos, as quantidades de drogas, as circunstâncias, as consequências e os antecedentes são negativos.

Quanto ao tipo, cocaína, crack e skunk são drogas com altíssimo poder de dependência química. Possuem nocividade bastante alta, devendo ser considerada na reprimenda do crime.

Quanto à quantidade, foram apreendidos 303 microtubos de cocaína, com peso bruto de 347,82 gramas, 203 porções de maconha, com peso bruto de 446,77 gramas, 52 porções de crack, com peso bruto de 58,84 gramas, e 13 porções de skunk, com peso bruto de 18,73 gramas. A quantidade e a variedade são altas e extrapolam consideravelmente o ínsito ao tipo.

Quanto às circunstâncias, o crime foi praticado de forma bastante sofisticada e em concurso de agentes. Durante a campanha, os policiais acompanharam toda a empreitada criminosa. Explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". Os réus atuavam de forma especialmente organizada, de forma a dificultar a identificação do crime. Essa circunstância torna o crime ainda mais reprovável e deve ser considerada na dosimetria da pena.

Quanto às consequências do crime, o local, amplamente conhecido no meio policial por "favela do caixote", é ponto tradicional de venda e consumo de entorpecentes, situado às margens do Rio Preto e com geografia que dificulta bastante as ações policiais. Trata-se de local com intensa atividade de traficância, com diversas ocorrências semelhantes, liderado por organização criminosa de altíssima periculosidade (o PCC), que se vale da venda de drogas para financiar suas atividades criminosas. As consequências, não só às pessoas daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta pelo menos 2 condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, dentre as quais destaco 1 delas a título de mau antecedente: processo 0000319-86.2012.8.26.0441, com acórdão condenatório proferido em 13/07/2016, transitado em julgado para o MP aos 12/09/2016 e para a defesa aos 28/11/2016 (fl. 353).

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão (Súmula 545, STJ). Carlos Eduardo confessou que traficava no local há cerca de 6 meses. Mas o seu histórico e comportamento revelam que exercia a traficância há muito mais tempo.

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta pelo menos 2 condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, dentre as quais destaco 1 delas a

título de reincidência: processo 0001562-26.2016.8.26.0441, com sentença condenatória proferida em 14/02/2017, transitada em julgado para o MP e para a defesa aos 20/02/2017 (fl. 354). Há reincidência específica, portanto. Também incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito em plena luz do dia, acreditando, porém, que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seria abordado pela polícia. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a preponderância da reincidência específica sobre a atenuante da confissão, o que impede a integral compensação, fixo a pena intermediária em 8 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O STJ pacificou que a utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem. Isso porque a reincidência, ao incidir na 2ª ou na 3ª fase, cumpre finalidades distintas: "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)".

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o réu ostenta mau antecedente e reincidência específicos. E mais: a atividade demonstrou ampla profissionalização. O crime foi praticado em concurso de agentes. Os réus atuavam de forma bastante organizada. Os policiais explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". O local, como ficou claro em audiência, trata-se de ponto de venda de drogas de alta rentabilidade, com diversas ocorrências semelhantes e liderado por organização criminosa. Ainda que o réu não ocupe papel de destaque na hierarquia criminosa, claramente aceitou integrar essa estrutura organizada. A forma de acondicionamento e o local da prisão em flagrante denotam o considerável grau de profissionalização do acusado. Esse fato deve ser sopesado à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena, notadamente à luz da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual. O réu, efetivamente, se dedica a atividades criminosas.

Fixo a pena definitiva em 8 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, do histórico do réu, que apresenta maus antecedentes e reincidência específicos, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2, "a", CP).

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

RÉU RICARDO PEREIRA

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que os tipos, as quantidades de drogas, as circunstâncias, as consequências e os antecedentes são negativos.

Quanto ao tipo, cocaína, crack e skunk são drogas com altíssimo poder de dependência química. Possuem nocividade bastante alta, devendo ser considerada na reprimenda do crime.

Quanto à quantidade, foram apreendidos 303 microtubos de cocaína, com peso bruto de 347,82 gramas, 203 porções de maconha, com peso bruto de 446,77 gramas, 52 porções de crack, com peso bruto de 58,84 gramas, e 13 porções de skunk, com peso bruto de 18,73 gramas. A quantidade e a variedade são altas e extrapolam consideravelmente o ínsito ao tipo.

Quanto às circunstâncias, o crime foi praticado de forma bastante sofisticada e em concurso de agentes. Durante a campanha, os policiais acompanharam toda a empreitada criminosa. Explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". Os réus atuavam de forma especialmente organizada, de forma a dificultar a identificação do crime. Essa circunstância torna o crime ainda mais reprovável e deve ser considerada na dosimetria da pena.

Quanto às consequências do crime, o local, amplamente conhecido no meio policial por "favela do caixote", é ponto tradicional de venda e consumo de entorpecentes, situado às margens do Rio Preto e com geografia que dificulta bastante as ações policiais. Trata-se de local com intensa atividade de traficância, com diversas ocorrências semelhantes, liderado por organização criminosa de altíssima periculosidade (o PCC), que se vale da venda de drogas para financiar suas atividades criminosas. As consequências, não só às pessoas daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta pelo menos 2 condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, dentre as quais destaco 1 delas a título de mau antecedente: processo 0001400-70.2012.8.26.0441, com sentença condenatória proferida em 26/11/2012, transitado em julgado para o MP e para a defesa aos 18/02/2013 (fl. 362).

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta pelo menos 2 condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, dentre as quais destaco 1 delas a título de reincidência: processo 0003263-32.2010.8.26.0441, com sentença

condenatória proferida em 20/11/2014, transitada em julgado para o MP aos 30/01/2015 e para a defesa aos 03/07/2015 (fl. 362). Há reincidência específica, portanto.

Também incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito em plena luz do dia, acreditando, porém, que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seria abordado pela polícia. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Considerando a maior reprovabilidade da reincidência específica, fixo a pena intermediária em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O STJ pacificou que a utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem. Isso porque a reincidência, ao incidir na 2ª ou na 3ª fase, cumpre finalidades distintas: "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)".

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o réu ostenta mau antecedente e reincidência específicos. E mais: a atividade demonstrou ampla profissionalização. O crime foi praticado em concurso de agentes. Os réus atuavam de forma bastante organizada. Os policiais explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". O local, como ficou claro em audiência, trata-se de ponto de venda de drogas de alta rentabilidade, com diversas ocorrências semelhantes e liderado por organização criminosa. Ainda que o réu não ocupe papel de destaque na hierarquia criminosa, claramente aceitou integrar essa estrutura organizada. A forma de acondicionamento e o local da prisão em flagrante denotam o considerável grau de profissionalização do acusado. Esse fato deve ser sopesado à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena, notadamente à luz da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual. O réu, efetivamente, se dedica a atividades criminosas.

Fixo a pena definitiva em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, do histórico do réu, que apresenta maus antecedentes e reincidência específicos, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2, "a", CP).

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

RÉU JOSÉ DOMINGOS JESUS DOS SANTOS

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que os tipos, as quantidades de drogas, as circunstâncias, as consequências e os antecedentes são negativos. Quanto ao tipo, cocaína, crack e skunk são drogas com altíssimo poder de dependência química. Possuem nocividade bastante alta, devendo ser considerada na reprimenda do crime.

Quanto à quantidade, foram apreendidos 303 microtubos de cocaína, com peso bruto de 347,82 gramas, 203 porções de maconha, com peso bruto de 446,77 gramas, 52 porções de crack, com peso bruto de 58,84 gramas, e 13 porções de skunk, com peso bruto de 18,73 gramas. A quantidade e a variedade são altas e extrapolam consideravelmente o ínsito ao tipo.

Quanto às circunstâncias, o crime foi praticado de forma bastante sofisticada e em concurso de agentes. Durante a campanha, os policiais acompanharam toda a empreitada criminosa. Explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". Os réus atuavam de forma especialmente organizada, de forma a dificultar a identificação do crime. Essa circunstância torna o crime ainda mais reprovável e deve ser considerada na dosimetria da pena.

Quanto às consequências do crime, o local, amplamente conhecido no meio policial por "favela do caixote", é ponto tradicional de venda e consumo de entorpecentes, situado às margens do Rio Preto e com geografia que dificulta bastante as ações policiais. Trata-se de local com intensa atividade de traficância, com diversas ocorrências semelhantes, liderado por organização criminosa de altíssima periculosidade (o PCC), que se vale da venda de drogas para financiar suas atividades criminosas. As consequências, não só às pessoas daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Quanto aos antecedentes, o réu apresenta pelo menos 5 condenações definitivas, dentre as quais destaco 3 delas a título de Maus Antecedentes: processo 0002282-20.1999.8.26.0075, com sentença condenatória proferida em 28/06/2000, transitada em julgado para o MP e para a defesa aos 28/07/2000 (fl. 358); processo 0002631-53.2000.8.26.0280, com sentença condenatória proferida em 05/05/2005, transitada em julgada para o MP e para a defesa aos 03/08/2006 (fls. 342 e 359/360); e processo 0002713-84.2000.8.26.0280, com sentença condenatória proferida em 19/04/2002, transitada em julgado para o MP aos 15/09/2003 e para a defesa aos 18/11/2003 (fl. 360). Os antecedentes são especialmente negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos: (a) 1 ano para os Maus Antecedentes, porquanto são 3 antecedentes especialmente negativos; e (b) 6 meses para cada uma das demais circunstâncias negativas.

Assim, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta pelo menos 5 condenações definitivas, dentre as quais destaco 1 delas a título de reincidência: processo 0002060-38.2007.826.0280, com trânsito em julgado para o MP aos 11/06/2015 e para a defesa aos 21/07/2015 (fl. 343). Há reincidência, portanto.

Também incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito em plena luz do dia, acreditando, porém, que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seria abordado pela polícia. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Fixo a pena intermediária em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O STJ pacificou que a utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem. Isso porque a reincidência, ao incidir na 2ª ou na 3ª fase, cumpre finalidades distintas: "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)".

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o réu ostenta mau antecedente e reincidência específicos. E mais: a atividade demonstrou ampla profissionalização. O crime foi praticado em concurso de agentes. Os réus atuavam de forma bastante organizada. Os policiais explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". O local, como ficou claro em audiência, trata-se de ponto de venda de drogas de alta rentabilidade, com diversas ocorrências semelhantes e liderado por organização criminosa. Ainda que o réu não ocupe papel de destaque na hierarquia criminosa, claramente aceitou integrar essa estrutura organizada. A forma de acondicionamento e o local da prisão em flagrante denotam o considerável grau de profissionalização do acusado. Esse fato deve ser sopesado à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena, notadamente à luz da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual. O réu, efetivamente, se dedica a atividades criminosas.

Fixo a pena definitiva em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, do histórico do réu, que apresenta maus antecedentes e reincidência, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2, "a", CP).

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para: (a) CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO PEREIRA, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 dias-multa, no mínimo legal cada; (b) CONDENAR o réu RICARDO PEREIRA, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, no mínimo legal cada; e (c) CONDENAR o réu JOSÉ DOMINGOS JESUS DOS SANTOS, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, c/c art. 29 do CP, às penas de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, no mínimo legal cada. Os réus deverão permanecer presos.

Concretamente, trata-se de crime bastante grave. Foram apreendidos 303 microtubos de cocaína, com peso bruto de 347,82 gramas, 203 porções de maconha, com peso bruto de 446,77 gramas, 52 porções de crack, com peso bruto de 58,84 gramas, e 13 porções de skunk, com peso bruto de 18,73 gramas. A quantidade, a variedade e a nocividade das drogas ultrapassam o insito ao tipo. Os réus atuavam de forma quase profissionalizada. Os policiais explicaram que o réu CARLOS EDUARDO estava com uma bolsa, recebendo usuários de drogas, enquanto RICARDO recebia e guardava o dinheiro dos usuários consigo, sendo que JOSÉ atuava em ação típica de "olheiro". Havia, portanto, divisão de tarefas de forma especialmente organizada. O local, como ficou claro em audiência, trata-se de ponto tradicional de venda e consumo de entorpecentes, situado às margens do Rio Preto e com geografia que dificulta bastante as ações policiais. É localidade com intensa atividade de traficância, com diversas ocorrências semelhantes, e liderado por organização criminosa de altíssima periculosidade (o PCC), que se vale da venda de drogas para financiar suas atividades criminosas. Ficou claro que os réus se dedicaram intensamente a atividades criminosas.

E mais: os réus possuem maus antecedentes e reincidência. O réu Carlos Eduardo e o réu Ricardo possuem 2 condenações definitivas pelo crime de drogas, sendo ambos reincidentes específicos. Já o réu José conta com pelo menos 5 condenações definitivas, apresentando diversos maus antecedentes e reincidência. Os réus ainda cumpriam pena no regime aberto quando praticaram o delito. Voltaram a delinquir mesmo depois das diversas oportunidades que lhes foram dadas. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão preventiva, única medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pelos acusados.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, do comportamento e histórico dos réus e da alta probabilidade de reiteração delitiva. A manutenção da segregação cautelar dos réus é a medida que se impõe. Em razão do exposto, mantenho a prisão dos acusados, para a garantia da ordem pública.

Recomendem-se os réus onde encontram-se presos.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intimem-se os réus a pagarem a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se as Guias de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Condeno os réus ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA